Processo nº **0039393-60.2021.8.17.2001**

AUTOR: SERGIO DE AQUINO FONSECA

REU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

SERGIO DE AQUINO FONSECA ajuizou ação em face de **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,** buscando a: (i)declaração de nulidade de eventual cláusula abusiva que impeça a autorização de seu tratamento; (ii) condenação da ré a (ii.a) custear tratamento oncológico com o fármaco apalutamida, na dose diária de 240mg, ou outro que venha a ser prescrito no curso da doença; (ii.b) pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em face da recusa administrativa e de seu grave estado de saúde.

Afirma, em síntese, que:

a) mantém contrato de assistência à saúde com a demandada, (código 09003.0215.2469.0017), do tipo Especial II, de segmentação ambulatorial e hospitalar, e está adimplente com as mensalidades;

b) foi diagnosticado como portador de Neoplasia Maligna da Próstata, em razão do que o seu médico assistente indicou, a fim de melhorar seu quadro clínico, e em caráter de urgência, o uso do medicamento antineoplásico APALUTAMIDA, pelo período de 30 (trinta) dias, 240mg ao dia, referente ao primeiro ciclo do tratamento;

c) malgrado o tratamento seja necessário para a sua recuperação, a ré não autorizou o medicamento, sob o fundamento de que "de acordo com a cláusula de cobertura do seu contrato, somente há cobertura para os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS".

Requereu os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito.

Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, que a operadora ré fosse compelida a autorizar o tratamento com a medicação APALUTAMIDA, 240mg, conforme prescrição médica.

Juntou documentos.

Deferida a tutela provisória de urgência (ID 82095487), a ré fez prova de seu cumprimento (ID 83536266).

Instada a juntar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, a parte autora recolheu as custas processuais (SICAJUD).

Citada, a Sul América apresentou contestação (ID 83907876). Alega, em síntese, que:

a) o contrato pactuado pelo autor é antigo e não adaptado, não se lhe aplicando a Lei n.º 9.856/98;

b) está adstrita à cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, dentre os quais não se encontra o custeio do tratamento pretendido pelo demandante;

c) outrossim, o fornecimento do medicamento pretendido nos autos somente é assegurado ao beneficiário do contrato de assistência à saúde nos casos especificados na DUT n. 64 da ANS;

d) inexiste qualquer fato ensejador de indenização por danos morais, já que agiu na mais estreita legalidade e respeitou os limites contratualmente estabelecidos.

Juntou documentos.

A parte autora apresentou réplica (ID 92414405).

Instadas, as partes não demonstraram interesse na produção de provas complementares (ID 105295351 e 109756260).

É o que importa relatar. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do disposto no art.355, I, do CPC/2015, porquanto desnecessária a produção de outras provas. Destaque-se ainda que, conquanto intimadas para especificar as provas cuja produção tivessem interesse, as partes nada requereram.

No relatório médico (ID 81868366- pág. 1), o especialista: (a) atesta que o paciente foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata Gleason 9, metastático para linfonodos sensíveis à castração (Neoplasia Maligna da próstata – CID C61); (b) solicita tratamento oncológico com zoladex 10,8 mg a cada 3 (três) meses, associado à apalutamida 240 mg/ao dia, contínuo, até a progressão da doença ou toxicidade limitante, aos moldes do estudo "Titan".

O documento de ID 81868367 faz prova da recusa de autorização do tratamento pela demandada, em 01.06.2021, sob a justificativa de que a documentação enviada não atende aos critérios da Diretriz de Utilização (DUT) 64, estabelecida pela ANS para o procedimento em questão.

O contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária a parte autora foi celebrado antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998 e não foi a ela adaptado (ID 80907877), sendo certo que, à luz do entendimento firmado pelo STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)n. 1931, **as disposições da Lei nº 9.656/1998 são inaplicáveis *in casu*.**

Em sessão do dia 7.2.2018, **o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgando parcialmente procedente a ADI n. 1931**, que questionava a Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), considerou válida a maioria dos dispositivos questionados, mas entendeu que **os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde.** No particular, o acórdão encontra-se assim ementado: **"Os planos de saúde submetem-se aos ditames constitucionais, à legislação da época em que contratados e às cláusulas deles constantes".**

Todavia, ainda que afastada a aplicação da Lei nº 9.656/1998, não se pode olvidar que o contrato firmado entre as partes encerra relação de consumo, subsumindo-se à Lei nº 8.078/1990, nos exatos termos do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

No caso apresentado nos autos, verifico que a ré não indicou cláusula contratual específica para afastar a cobertura da terapia neoplásica oral prescrita pelo médico assistente. Limitou-se, em verdade, a negar a sua cobertura com base em Rol de Procedimentos que sequer se aplica ao contrato do qual o demandante é beneficiário.

O contrato antigo e não adaptado, consoante constatado, não se submete à Lei de Plano de Saúde e, consequentemente, ao Rol de Procedimentos e Eventos da ANS.

De uma análise das condições gerais do contrato apresentado no ID 83907880, notadamente da cláusula 9, não vislumbro limitação expressa de cobertura para tratamento antineoplásico pretendido nos autos.

Ao se comprometer com o tratamento de determinada enfermidade, a operadora cria, no consumidor, a legítima expectativa de que terá acesso aos meios terapêuticos prescritos para debelar – ou minimizar – os efeitos da patologia enfrentada. Impedir que o autor tenha acesso ao tratamento **integral** em razão de um dos fármacos prescritos ser ministrado em regime domiciliar **é medida inegavelmente abusiva.**

Com o paulatino avanço da medicina, muitos protocolos vêm sendo simplificados, de modo que tratamentos que antes exigiam internação ou que eram realizados em clínicas, inclusive com risco de exposição do paciente

a infecções as mais diversas, **vêm sendo substituídos por injeções administradas pelo próprio paciente em ambiente domiciliar** ou **mesmo por medicação oral.** É exatamente o caso dos autos.

Em casos tais, a negativa de fornecimento de fármaco para administração em ambiente domiciliar levaria a situação de inaceitável iniquidade, em que o paciente haveria de permanecer em leito hospitalar ou mesmo dirigir-se à clínica, sob pena de lhe ser negada a cobertura, quando, na verdade, o tratamento se afigura mais eficaz se realizado independentemente de internação.

Demais disso, resta pacificado na jurisprudência do STJ que somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, **não estando a seguradora habilitada, nem tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.** Isso porque a seguradora não pode substituir-se aos médicos na opção terapêutica. Assim, se a patologia está prevista no contrato, não pode haver qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico quando da avaliação do paciente e de sua patologia, por quem não detém técnica nem competência para fazê-lo.

Confira-se:

> *"A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n ° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato.* **Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente.** *E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto* **quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.** *Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n ° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n ° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02). Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de*

tratamento está alcançado para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor" (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 29/06/2007).

No mesmo sentido ainda STJ - Resp. 1.053.810-SP.

Nesse contexto, ao tempo em que **tomo por injusta a recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso** solicitado pelo médico assistente, **confirmo os efeitos da decisão antecipatória de tutela** deferida nos autos, ainda que por outros fundamentos.

A pretensão de reparação civil por danos morais também merece acolhida.

Malgrado, em regra de princípio, o mero inadimplemento contratual seja insuficiente à configuração de danos extrapatrimoniais, a jurisprudência vem reconhecendo que a indevida recusa a cobertura de contrato de assistência à saúde pode sim ensejar a configuração de dano moral indenizável (STJ: AREsp 946150/SP; AREsp 919439/RJ; AREsp 708894/DF; AgInt no AREsp 1022746/RN; AgRg no AREsp 666568/RJ).

É que, se de um lado é certo que, no mais das vezes, o não cumprimento de obrigação contratual impõe prejuízos de ordem unicamente material, de outro, importa ver que, em determinadas circunstâncias, o descumprimento do contrato pode exacerbar a seara patrimonial, dando causa a uma violação dos direitos da personalidade, ao comprometimento da honra, da dignidade ou da intimidade da pessoa humana, ou mesmo deflagrando ou agravando séria e compreensível situação de angústia, insegurança, aflição ou dor psíquica e/ou física de quem já se acha com a saúde debilitada. Nessas situações, do descumprimento do contrato decorrerá não só danos materiais, mas também morais, e, dado que a Constituição da República adotou o princípio da reparação integral (art. 5°, V e X), além de responder pelas perdas e danos materiais (art. 389 do CC), o responsável pelo inadimplemento deverá indenizar também os danos extrapatrimoniais.

Certamente, a recusa na autorização do tratamento médico solicitado pela autora e prescrito pelo seu médico assistente, em razão do diagnóstico de "adenocarcinoma de próstata Gleason 9 metastático para lifonodos sensível

à castração", foi suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica da qual inexoravelmente já se achava acometido o paciente.

Em verdade, não há como deixar de reconhecer que o promovente, já extremamente desgastado física e emocionalmente, viu-se inesperadamente desamparado justamente por aquele que foi contratado e remunerado para ampará-lo nessa circunstância.

Ora, quem se vincula a contrato de assistência à saúde o faz em busca de segurança e confiança futura para os seus bens mais preciosos: a saúde e a vida. Assim, o descumprimento de contrato dessa natureza, ao frustrar tais expectativas, impingindo ao paciente a sensação de abandono, à toda evidência é capaz de causar-lhe profunda dor psíquica e sofrimento indenizável a título de dano moral.

À vista de tais considerações, tenho como configurados o dano moral e o dever de indenizar.

Fixo o valor da indenização.

A indenização em face do dano moral tem caráter reparatório e punitivo-pedagógico. De um lado, objetiva reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia experimentada pelo lesado. De outro, visa motivar o ofensor a adotar novas práticas, cercando-se de novos cuidados, a fim de não mais incidir em condutas ilícitas da mesma natureza, vale dizer, tenciona impedir a repetição de fatos idênticos ou assemelhados.

De realçar ainda a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na fixação do quantum indenizatório de dano moral "[...] recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (REsps. nºs. 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP).

No caso dos autos, tenho que a demandada agiu com culpa grave, pois quando da desídia em autorizar o tratamento do autor, tinha ciência das complicações e dos riscos do seu quadro de saúde. Inarredável a conclusão de que o descumprimento contratual foi voluntário e consciente, agindo a ré com culpa grave.

Por outro lado, a demandada é empresa de significativo porte financeiro. Indenização modesta em termos pecuniários certamente não a estimulará a revisar conceitos e comportamentos com o objetivo de não mais praticar a conduta ilícita. Ademais, indenizações módicas têm permitido que os fornecedores em geral lucrem com a ofensa moral, preferindo, aqui e ali,

arcarem com indenizações a aparelharem-se adequadamente segundo as exigências do mercado consumidor e as interpretações assentadas pelo Poder Judiciário.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando sobretudo as peculiaridades do caso, já bem delineadas, para garantir à parte autora a justa reparação pelos danos sofridos, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ainda atenta ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À vista do exposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, julgo procedentes os pedidos (art. 487, I do CPC/2015) e, confirmando os efeitos da decisão antecipatória, condeno a demandada **Sul América Companhia de Seguro Saúde** a:

1.custear o tratamento com a medicação APALUTAMIDA, na dose diária de 240mg, de uso contínuo, até progressão ou toxicidade limitante, consoante prescrição médica (ID 81868366);

2. pagar ao demandante, a título de indenização por danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária (índices da tabela do Encoge), a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), e de juros legais de mora (1% - um por cento ao mês - art. 406 do CC c/c art. 161, §1°, do CTN), a partir da data da citação (art. 405 do CC);

3. pagar ao(s) advogado(s) constituído(s) pela parte autora honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pela demandante, que corresponde à soma do valor da indenização por danos morais com o valor dos custos do tratamento médico cuja cobertura foi imputada à ré, tudo com fulcro no art. 85, §2°, do CPC/2015 e na Súmula 27 do TJPE.

4. ressarcir à parte autora o valor recolhido a título de adiantamento de custas e despesas processuais (R$700,00), atualizados pela Tabela Encoge desde a data de desembolso (09.06.2021).

Opostos embargos de declaração com efeito modificativo, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (art. 1.023, § 2°, do CPC/2015), e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões (art. 1010, §1°, do CPC/2015). Havendo alegação – em sede de contrarrazões - de questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportaram agravo de instrumento, intime-se a parte adversa (recorrente) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009, §§ 1° e 2°, do CPC/2015). Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se a parte apelante para

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §2º, do CPC/2015). Em seguida, com ou sem resposta, sigam os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com os cumprimentos deste Juízo (art. 1010, §3º, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, independentemente de nova determinação. Intimem-se.

Recife/PE, data da assinatura digital.
Cristina Reina Montenegro de Albuquerque
Juíza de Direito Substituta em exercício cumulativo

Assinado eletronicamente por: CRISTINA REINA MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE
10/08/2022 21:23:43
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 111941580

22081021234328200000109453730

IMPRIMIR GERAR PDF